

1504157-47.2021.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Augusto Reinert de Freitas

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... dos autos é elemento valioso na análise da adequação típica do tráfico de drogas. Sobre o assunto:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO RECURSAL PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO TRÁFICO DE DROGAS. AS DENÚNCIAS ANÔNIMAS INFORMANDO A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504157-47.2021.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504157-47.2021.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2255531/2021 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 20342850 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO,

1844/21/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2255531 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS,

1844/21/505 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO ANGELO OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Augusto Reinert

Vistos.

LEONARDO ANGELO OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Consta da denúncia que, no dia 19 de setembro de 2021, às 22h00, na Rua Agostinho Paiva, n.º 63, Vila Boa Esperança, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu, para fins de

tráfico, trazia consigo 20 (vinte) pedras – com massa de 23,69 gramas – de “crack”, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (certidão de fl. 89) e a defensora nomeada apresentou defesa preliminar (fls. 83/87).

A decisão de fls. 91/92 recebeu a denúncia no dia 16 de novembro de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 118).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foi ouvida uma testemunha comuns.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta do crime previsto no artigo 33, caput, para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06. Em caso de condenação no delito de tráfico, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, bem como a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal, que se destina à apuração da responsabilidade do acusado LEONARDO ANGELO OLIVEIRA, pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada.

Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição e apreensão de fl. 10, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 13/14 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 98/101, sem deixar de mencionar a prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, decorre do depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Na fase extrajudicial, o policial militar André Luiz Rosa declarou que estava na companhia de seu colega de farda Cabo Bernardes encerrando uma ocorrência, quando se depararam com dois indivíduos na Rua Alberto Mori. Quando perceberam a viatura, esses indivíduos demonstraram nervosismo e adentraram a Rua Agostinho Paiva, assim, os policiais retornaram e visualizaram o réu subindo a árvore e o outro indivíduo havia fugido. Na abordagem pessoal do réu foi localizado com ele “crack” Há conhecimento e denúncias de que o réu está na traficância. Com ele foi encontrado pedras de “crack” já embaladas e pedras de “crack” em estado bruto. Possui passagem por furto. (fl. 03 – mídia audiovisual).

Na fase extrajudicial, o policial militar Marcio Bernardes declarou que estava na companhia de seu colega de farda quando atenderam uma ocorrência de desinteligência familiar e estavam saindo do bairro, quando se depararam com dois indivíduos andando pela rua. No momento que estes indivíduos perceberam a presença da viatura militar, aceleraram o passo e viraram a rua. Os policiais deram a volta no quarteirão e encontraram um dos indivíduos subindo em uma árvore. Desceu da viatura e abordou o indivíduo que estava subindo na árvore, Leonardo, com quem foi encontrado em seu bolso quatro embalagens com drogas, aparentemente “crack”. Não encontraram o outro

indivíduo. Indagado o réu sobre o outro indivíduo, respondeu não o conhecer. Em uma das embalagens havia pedras de "crack" já embaladas e as outras embalagens as pedras de "crack" estavam em seu estado bruto. O réu é conhecido nos meios policiais, já foi abordado pela testemunha em outra ocasião. O soldado André tem notícia de que o réu pratica a traficância. (fl. 02 - mídia audiovisual). Em Juízo, o policial militar Marcio declarou que estava na Rua Agostinho Paiva para atender uma ocorrência de desinteligência e posteriormente, ao sair do bairro e acessar a Rua Alberto Mori se deparou com o réu na companhia de outro indivíduo. Ambos estavam caminhando pela calçada e ao avistarem a viatura da polícia militar passaram acelerar suas passadas e foram em direção a Rua Agostinho Paiva. Imediatamente retornou a referida Rua, na companhia de seu colega de farda, o policial André, e avistou o réu escalando uma árvore em um terreno de esquina. Não encontraram o outro indivíduo que estava com o réu. O réu foi interceptado e abordado, com ele foi encontrado um plástico de cor azul com pedras de "crack" em estado bruto e seis pedras de "crack" já embaladas para a venda. O réu entrou em desespero com a abordagem policial e não deu maiores explicações. No momento da abordagem chegou ao local uma moça, a qual informou conhecer o réu e esta acompanhou a abordagem policial. O réu é conhecido nos meios policiais e há denúncias de que o réu está na traficância, bem como salientou que ele já foi preso anteriormente pelo mesmo crime. O réu também já foi citado em participação de furto em outras ocasiões. Não possui inimizade e nem rixas com o réu. (fl. 122 - mídia audiovisual).

Interrogado perante autoridade policial, o réu Leonardo Angelo Oliveira declarou que estava "indo embora", quando os policiais passaram por ele e disseram "a lá o neguinho". Ficou com medo e correu, subindo em uma árvore. Não possuía drogas consigo. Os policiais lhe agrediram e sua ex-esposa chegou ao local e entrevistou. Foi forjado pelos policiais, eles lhe avisaram que iriam fazer isso. Possui passagem por furto. (fl. 04 - mídia audiovisual).

Interrogado em Juízo, o réu negou o crime a ele imputado pela denúncia. Disse que estava virando uma esquina e se assustou com a presença dos policiais militares, uma vez que possui uma rixa com um deles, o qual já quase prendeu seu primo. Um dos policiais militares falou "olha ele lá, era ele mesmo que eu queria". Assustou e subiu em uma árvore. Não possuía drogas consigo. Os policiais militares arremessaram contra ele um capacete. Não sabe onde os policiais encontraram aquele capacete. Foi agredido pelos policiais e posteriormente foi levado para a delegacia de polícia. Não sabe o nome dos policiais, apenas conhece de "vista". Estava acompanhado de seu primo, o qual também se escondeu em uma árvore e viu todo o ocorrido. O seu primo se escondeu por ter se assustado com a presença dos policiais. Indagado sobre o motivo de terem se escondido, o réu esclareceu que inicialmente ele e seu primo estavam em uma motocicleta, quando estacionaram e passaram a caminhar com os capacetes em mãos e a chave da motocicleta. Quando viu um dos policiais militares, o qual disse "olha lá" e por medo dos policiais acharem "a moto e a chave com a gente, a gente pegou e correu". Não possui carteira nacional de habilitação e por isso correu. Já foi condenado pelo crime de receptação anteriormente. Trabalha de servente de pedreiro e recebe o valor de R\$ 1.500,00 mensais. Não conhece a pessoa de João Victor B. Tiveron, o médico que teria realizado o seu exame de corpo de delito. Negou ter realizado qualquer tipo de exame médico. (fl. 122 - mídia audiovisual).

Estas foram, em resumo, as provas produzidas em cenário judicial, observadas as regras pertinentes ao devido processo legal, em especial do contraditório e da ampla defesa.

A negativa do acusado está isolada nos autos. A traficância está bem evidenciada, cristalina.

Como se vê, os relatos prestados, tanto em juízo quanto na fase policial, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si, inexistindo quaisquer elementos que permitissem a ilação de que as testemunhas estariam animadas do propósito de incriminar indevidamente o acusado.

Os policiais militares narraram de forma harmoniosa na fase policial e em Juízo que em patrulhamento pela Rua Alberto Mori se depararam com dois indivíduos caminhando

pela calçada, sendo que ao notarem a presença da viatura policial demonstraram nervosismo e passaram a acelerar os passos, adentrando a Rua Agostinho Paiva. Diante da conduta suspeita dos indivíduos, os policiais também adentraram a Rua Agostinho Paiva e avistaram o réu Leonardo escalando uma árvore e não mais avistaram o outro indivíduo. O réu foi abordado e com ele foi encontrado um invólucro azul com uma porção bruta de "crack" e mais seis porções de "crack", já embaladas e prontas para a venda. Os policiais ainda narraram que havia informação do tráfico de drogas praticado pelo réu.

Com efeito, a droga apreendida, que o réu trazia consigo, destinava-se à venda, o que se extrai das circunstâncias do caso concreto, vale dizer, pela quantidade, natureza e forma que acondicionada a droga, sendo apreendido com o réu 20 (vinte) pedras de "crack" - com massa de 23,69 gramas - parte já embaladas e prontas para a venda e partes em estado bruto, conforme se extrai do auto de exibição e apreensão de fl. 10, laudos de constatação provisória de fls. 13/14, conjugado com laudo definitivo de entorpecentes de fls. 98/101; bem como pelos relatos dos policiais militares, que narraram que o réu, ao perceber a presença policial, tentou se esconder e subiu em uma árvore, além de que havia informação de que o réu praticava o tráfico de drogas.

Vale recordar, que a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância, tendo em vista consistir o crime de tráfico de em tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer das 18 ações tipificadas (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, terem depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), dispensada a prova do ato da mercancia em si, perfilhando desse mesmo entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos." (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 01.07.2016)

"TÓXICO Crime de tráfico Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimentos de agentes policiais. Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz em cada caso concreto Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório Policial que se diz usuário Flagrante legal Tipo penal misto alternativo que dispensa a prova da conduta da venda para a prisão e acusação. Condenação mantida Pena correta e adequada ao caso Regime fechado mantido. Recurso improvido." (TJSP, Relator (a): Newton Neves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2015; Data de registro: 01.04.2015).

Anoto que o valor do depoimento testemunhal dos servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Nesse sentido:

"A prova policial só deve desprezada, afastada, como elemento válido e aceitável de convicção, quando totalmente ausente prova judicial confirmatória ou quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes colhidos em juízo através de regular instrução. Havendo, porém, prova produzida no contraditório, ainda que menos consistente, pode e deve aquela ser considerada e chamada para em conjunto com esta, compor quadro probante suficientemente nítido e preciso (RJTERGS 150/143-3)" (Julio Frabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., p. 89, Atlas, 2000).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

“O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido” (STJ – RESP 200500786783 – (751760 MG) – 5ª T. – Rel. Min. Gilson Dipp – DJU 14.11.2005 – p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS – O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal – O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73518 – Relator: Min. Celso de Mello – 1ª Turma – J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendesse prejudicar o réu, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

O réu narrou em Juízo que seu flagrante foi forjado e que foi agredido pelos policiais militares. Disse ainda que estava na companhia de um primo e que sua ex-companheira chegou logo em seguida.

Contudo, além do réu não ter arrolado essas pessoas que teriam presenciado os fatos para serem inquiridas em Juízo e corroborar sua versão, o exame médico a qual submetido (cuja realização o réu também negou em Juízo), atestou a inexistência de lesões de interesse médico-legal.

Assim, a versão do acusado é evasiva e inverossímil, além de não ter sido demonstrada pela Defesa por qualquer meio de prova, que, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 156 do CPP.

Sob tais fundamentos, entre a versão dos policiais militares e a versão do réu, privilegia-se a dos primeiros. Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS ROBUSTAS CONTRA O ACUSADO. PLEITO DE FLAGRANTE FORJADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ALEGAÇÃO. ARGUMENTO DE CONDENÇÃO BASEADA APENAS NO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR. VALIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. PRESENÇA NOS AUTOS DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A condenação do acusado está satisfatoriamente fundamentada nas provas juntadas aos autos, consubstanciadas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, no Auto de Apresentação e Apreensão, no Laudo Pericial Toxicológico e no depoimento do policial responsável pela prisão do apelante. 2. Não há nos autos qualquer prova de que o flagrante foi forjado pelos policiais, nem menção do motivo ou interesse que os policiais tivessem para produzir provas contra um inocente. Dessa forma, o argumento não merece prosperar. 3. O testemunho de policiais tem o mesmo valor probatório do depoimento de outras testemunhas, haja vista que submetido às mesmas regras referentes ao juramento e à pena de falso testemunho, além de também ser colhido sob o crivo do contraditório. Assim, como qualquer outro meio de prova, o depoimento de policiais é, portanto, idôneo para fundamentar a condenação. Precedentes do STF e STJ.” (TJSP - Processo: APL 174120078171360PE000001741.2007.8.17.1360. Relator(a): Marco Antônio Cabral Maggi. Julgamento: 23/09/2011. Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal.).

Sobre a destinação da droga, é de se destacar que foram apreendidas com o réu 20 (vinte) pedras de "crack" - com massa de 23,69 gramas - parte já embaladas e prontas para a venda e partes em estado bruto, o que conduz à segura conclusão de que a droga se destinava ao comércio ilícito, e não ao uso próprio, pois é cediço que, em casos de tráfico, a substância entorpecente, no mais das vezes, é repartida em porções individuais para facilitar o comércio a terceiros.

Nesse sentido:

"Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - rel. ENÉAS MACHADO COTTA, RDTJRJ 23/288).

"Identificando o fornecedor das substâncias tóxicas, em poder de quem foi apreendida expressiva quantidade de cocaína, parte já dividida em dezenas de papelotes, prontos para entrega a consumo, impõe-se a condenação por tráfico, sem que se possa, todavia, reconhecer associação com compradores." (TJRJ - rel. PAULO GOMES DA SILVA FILHO, RDTJRJ 20/313).

Nesse interim, a literatura jurídica revelou que usualmente cada porção de maconha equivale a 0,6 grama (STJRHC nº 37.033/MG - Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz - j. 22.10.2013); cada porção de cocaína equivale a cerca de 0,25 grama (STF HC nº 111.247/MG 2ª Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski - j. 27.03.2012), cada porção de crack equivale a cerca de 0,1 grama (STFHC nº 114.390/RS 1ª Turma Relator Ministro Luiz Fux j. 20.08.2013).

Com base nestes dados, conclui-se que a quantidade de "crack" apreendida (23,69g) seria suficiente para produzir aproximadamente 236 porções individualizadas da droga.

Ainda, realce-se "que, consoante a literatura médica e a jurisprudência, a dose letal aos usuários de cocaína corresponde a 0,02g do tóxico; portanto, a quantidade da substância apreendida (7,97g) representa, pelo menos, 398 porções "insuportáveis", ensejando quadro de overdose (Delton Croce e Delton Croce Júnior, "Manual de Medicina Legal", 5ª edição, Editora Saraiva, 2.004, nº. 14.2.11.3, pg. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, "Medicina Legal e Antropologia Forense", 1ª edição, 1.988, nº. 42, pg. 539; STJ, HC 235.257/DF, DJe 26-3-2013; TJESP, Apelação Criminal nº. 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO), detalhe apto a reforçar o vil comércio" (TJSP - Apelação Criminal nº 0004647-51.2018.8.26.0408. 2ª Câmara de Direito Criminal. Relator Desembargador COSTABILE E SOLIMENE. Julgamento em 05.08.2019).

Quanto às denúncias que recaem sobre o réu, no sentido de que estaria praticando o tráfico de entorpecentes, é certo que isoladamente denúncias anônimas não possuem o condão de condenar alguém, mas aliadas a outros elementos probatórios constituem indícios concretos da prática delitiva, como é o caso dos autos, na qual os policiais encontraram junto ao acusado 20 (vinte) pedras de crack, com massa líquida de 23,69 (vinte e três gramas e sessenta e nove centésimos).

Como se observa, ainda que as denúncias anônimas sejam provas indiciárias, quando corroboradas por outras provas dos autos é elemento valioso na análise da adequação típica do tráfico de drogas. Sobre o assunto:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO RECURSAL PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO TRÁFICO DE DROGAS. AS DENÚNCIAS ANÔNIMAS INFORMANDO A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA PELO APELANTE, OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E A POSSE DO RÉU DE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DEMONSTRAM SUA RESPONSABILIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DO CP. QUANTIDADE DOS TÓXICOS APREENDIDOS E PROVA NA HABITUALIDADE NA VENDA E PLANTIO, NÃO AUTORIZAM SUA APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO" (TJPR - 4ª C. Criminal - AC 0662493-3 - Siqueira Campos - Rel.: Des. Miguel Pessoa - Unânime - J. 01.07.2010) (destaquei).

"Tráfico de entorpecentes - Recurso do Ministério Público Pedido de Condenação do corréu Thiago. Acolhido Autoria e materialidade comprovadas para ambos os réus Robusto conjunto probatório - Seguros e insuspeitos relatos dos policiais militares que confirmaram: a denúncia anônima dando conta da prática do tráfico de drogas

praticado por dois indivíduos, passando, inclusive, as características deles; bem como a confissão informal dos dois acusados - Réu que foi visto dispensando quantia em dinheiro em notas amassadas - Atitude comum em coautoria na venda espúria, onde um agente é responsável pelas drogas e o outro pelo dinheiro. Pedido da acusação para aumento da pena base - Possibilidade - Quantidade e diversidade de drogas que justificam o acréscimo nesta etapa. Pedido da acusação para afastar a confissão do corréu Vanderson - Possibilidade - Confissão parcial feita com o intuito de excluir a culpabilidade de seu comparsa, e não com o escopo de auxiliar na resolução da ação criminal - Impossibilidade de concessão do benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas - Réus reincidentes - Regime fechado é medida necessária - Dado provimento ao recurso ministerial." (Apelação Criminal nº 1501052-47.2018.8.26.0544; 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Freitas Filho, julgamento em 09.10.2019) (destaquei).

Assim, as denúncias anônimas são importantes fontes de informações para a polícia e, quando são confirmadas com elementos concretos nos autos, merecem guarida para sustentar a acusação de tráfico de entorpecentes, pois não se pode esperar que a pessoa delatora de tão grave delito assuma sem temor sua identidade, ante a usual represália emanada dos inúmeros traficantes de drogas que mutuamente se ajudam. Portanto, em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável a desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, bem como inviável o acolhimento da tese que pretende a absolvição do réu sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria do tráfico.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu LEONARDO ANGELO OLIVEIRA, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Passo à aplicação de sua pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em análise às diretrizes previstas nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, verifico que o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, já que traficava "crack", conhecida por sua natureza altamente viciante, destrutiva e nociva à saúde humana.

Assim, "Há que se reconhecer a maior nocividade da cocaína em relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os efeitos deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência psicológica e física, por vezes imediata, por eles provocada, bem como as consequências sociais nefastas acarretadas pelo consumo e tráfico de tais entorpecentes" (STJ, HC 187330/MG, Relator Ministro GILSON DIPP, julgamento em 03.05.2011).

Sobre a nocividade da cocaína na forma de "crack", transcrevo trecho de julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Oportuno destacar que, em matéria jornalística veiculada na Folha de S. Paulo do dia 31.5.2015, noticiou-se estudo indicativo de que ao menos 1.685 pessoas morreram no Est. de S. Paulo em 2013 após terem consumido cocaína, uma média de cinco óbitos diários. E, "Segundo especialistas, o crack é 'cinco vezes mais potente que a própria cocaína e produz dependência com muita facilidade e quase imediatamente após seu primeiro ou segundo uso (...) Os efeitos produzidos ao usuário são basicamente iguais ao da cocaína, porém muito mais intensos (...)'" (João Gaspar Rodrigues, Tóxicos, Bookseller, 2001, p. 63)" (RT, 838/571). Sem dúvida, não se pode negar a nocividade da cocaína em pedra, que apresenta maior lesividade ao organismo humano, tornando o usuário, em curto - período de tempo, "escravo do desejo de consumir o entorpecente". Note-se, por oportuno, que "A cocaína fumada na forma de crack (...) possui ação farmacológica comparável à cocaína" (v. Toxicologia Forense cit., cap. V, nº 1.3.1, pág. 136)" (TJSP. Apelação Criminal nº 0004647-51.2018.8.26.0408. 2ª Câmara de Direito Criminal. Relator COSTABILE E SOLIMENE. Julgamento em 05.08.2019).

Sem dúvida, não se pode negar a nocividade da cocaína em pedra, que apresenta maior lesividade.

Portanto, essa circunstância (natureza) autoriza a exasperação da pena em face da maior reprovabilidade da conduta, na esteira do art. 42 da Lei de Drogas, que estabelece a quantidade e natureza da droga como circunstância preponderante na fixação da pena base.

Nesse sentido:

1. A natureza da droga apreendida - cocaína, dotada de alto poder viciante - constitui fundamento idôneo a ensejar a exasperação da pena-base, à luz do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (STJ, HC 338379/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 06.12.2016)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS (CRACK E COCAÍNA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes de tráfico de drogas, o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal - CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) justifica a majoração da pena-base, em relação à Debora, bem ainda a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em seu patamar mínimo, para o réu Geraldo. Precedentes. 3. Ag regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC 476995 / SC, 5ª Turma, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgamento em 03.05.2019.)

"O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos" (STJ, 5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12).

"No crime de tráfico de drogas, a quantidade e a variedade do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena base, amparada no art. 59 do Código penal, uma vez que, atendendo à finalidade da lei 6.368/76 (atual Lei n. 11.343/06), que visa coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esses fundamentos apresentam-se válidos para individualizar a pena, dado o maior grau de censurabilidade da conduta. Precedentes" (STJ, 5ª T., rel. Arnaldo Esteves Lima, 18.10.2007, v.u.). No mesmo sentido: STJ, HC 84.269-MS, 5ª Turma, rel. Napoleão Nunes Maia Filho, 11.12.2007, v.u.)

Assim, em primeira fase, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas (natureza e variedade das drogas), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Torno a pena definitiva, à mingua de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena.

Saliento que o caso concreto não se ajusta à figura do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33 § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois restou demonstrado que o réu se dedicava à atividade criminosa. Com efeito, os policiais militares narraram que havia informações do tráfico de drogas praticado pelo réu, evidenciando o tráfico reiterado de entorpecentes e que não se trata de uma traficante de primeira viagem (o que ensejaria a aplicação do redutor), e permite concluir que fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida, estando inserida no espúrio comércio há algum tempo.

Vale rememorar o texto legal:

"§ 4º Nos delitos definidos no caput em o §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa." (destaquei).

Vejam os a jurisprudência:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o condenado por tráfico de drogas, apreendido com grande quantidade de substância entorpecente, manifesta dedicação à atividade criminosa. 2. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 4,75g, na forma de 42 pedras de substância análoga ao crack, sendo inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art.33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 3. Por fim, indemonstrado, de plano, fato diverso que fragilize o decisum condenatório quanto à dedicação à traficância de drogas, impossível albergar a pretensão de realizar, através do writ, o revolvimento do conjunto fático probatório que arrimou o



mencionado fundamento. 4. Ordem denegada" (STJ: HC198458/SP, T5 - Quinta Turma, Min. Adilson Vieira Macabu Desembargador Convocado do TJ/RJ, Data 31/05/2011). Dada a natureza do crime, equiparado constitucionalmente aos hediondos; a quantidade de pena aplicada; a natureza da substância entorpecente apreendida ("crack"), sendo necessário o efetivo combate a tão grave conduta, concretamente considerada, entendo que o único regime adequado e suficiente para início de cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal, é o fechado.

E, pelos mesmos fundamentos, entendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por meras restritivas de direitos, incompatíveis com crime dessa natureza, ante sua equiparada hediondez, bem como insuficientes para o necessário combate ao comércio ilícito de drogas, que mais e mais assola a sociedade disseminando o vício. Inviável, igualmente, a aplicação do sursis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu LEONARDO ANGELO OLIVEIRA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, bem como ao pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

Considerando que o réu permaneceu em liberdade durante toda a instrução do processo, poderá recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF e (c) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Ao Dra. Defensora nomeada, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se as respectivas certidões.

Sendo o réu assistido por defensor dativo, deixo de condená-lo às custas processuais.

P.I.C.

Ourinhos, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA